

1500615-78.2021.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... assentado a ocorrência do delito de tráfico na conduta do réu e sua autoria, posto que pugna apenas por fixação da pena com o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

E, a prova dos autos, de forma segura e convincente demonstra a ocorrência dos fatos como narrados na denúncia, a configuração do delito de tráfico de drogas; a autoria deles pelo réu e a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Compl. do Endereço da Vara << Informação indisponível >> - Parque São Jorge

CEP: 19013-050 - Presidente Prudente - SP

Telefone: 18 33112386 - E-mail: prudente1cr@tjsp.jus.br

1500615-78.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500615-78.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

ALEX SILVA GOMES e outros

V I S T O S, E T C.

ALEX SILVA GOMES, qualificado à fls. 12, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia:

"Consta nos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 14 de julho de 2021, por volta de 19h50, na Rua Heitor Miranda, n.º 115, bairro Cidade Universitária, nesta cidade e comarca, o DENUNCIADO mantinha em depósito para fins de fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 9,0 (nove gramas) de maconha, acondicionada em 02 (dois) invólucros plásticos, e 5,0 (cinco) gramas da substância entorpecente denominada cocaína, acondicionada em 09 (nove) invólucros plásticos; bem como na Rua Nicolau Cassiotari, n.º 360, Jardim Bongiovani, nesta cidade e comarca, vendeu a Bruno Eduardo Oliveira da Silva, sem autorização e em desacordo com determinação

legal e regulamentar, 08 (oito) gramas de maconha e, ainda, na Rua Gerônimo Mora, n.º 287, Vila Formosa, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 78,0 gramas (setenta e oito gramas) de maconha, acondicionada em um invólucro plástico, e 02 (dois) comprimidos de droga sintética, e vendeu a Lucas Tondati Garcia (fl. 08), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 54 gramas (cinquenta e quatro gramas) de maconha, consoante auto de exibição e apreensão (fls. 36/39), fotografias (fls. 40/51) e laudo pericial definitivo de fls. 54/57. Segundo apurado, o denunciado adquiriu os entorpecentes acima descritos de pessoas até o momento não identificadas e os manteve em depósito em sua residência para posteriormente comercialização. Após, a droga era fracionada em porções menores e, valendo-se de seu automóvel VW Jetta, cor branca, placas FTF-4324 de Presidente Prudente-SP, ano 2014, o denunciado realizava a venda de entorpecentes a dependentes químicos. Contudo, Policiais Civis receberam denúncia anônima de que o denunciado estaria realizando a venda de entorpecentes, com menção ao veículo automotor acima. Ante a informação, policiais constataram o automóvel estacionado no endereço de ALEX. Diante da suspeita, os policiais estabeleceram ponto de observação a distância e averiguaram movimentação típica da venda de drogas na residência do denunciado. No dia dos fatos, o denunciado deixou sua casa e se dirigiu a Rua Nicolau Cassiotari, n.º 360, Jardim Bongiovani, nesta cidade, residência de Bruno Eduardo Oliveira da Silva (fl. 09). No local, vendeu ao morador 08 (oito) gramas de maconha, evadindo-se em seguida. Após, os policiais abordaram Bruno e constataram a aquisição da droga, procedendo à apreensão do entorpecente. Ato contínuo, o denunciado novamente saiu da sua residência e se dirigiu à Rua Gerônimo Mora, nº 287, com o mesmo veículo acima apontado. No local, vendeu 54 gramas (cinquenta e quatro gramas) de maconha a Lucas Tondati Garcia (fl. 08) pelo valor de R\$ 109,00 (cento e nove reais). Neste momento, os policiais abordaram o denunciado e Lucas, respectivamente, pela venda e compra de substância entorpecente. No veículo de ALEX foi localizado embaixo do banco do passageiro 78 gramas (setenta e oito gramas) de maconha, acondicionados em dois invólucros plásticos e com ele a quantia de R\$ 690,00 (seiscentos e noventa reais). Em prosseguimento as diligências, o denunciado e os policiais rumaram a residência daquele. Após franqueada a entrada e com a ajuda de cães farejadores, foram encontrados 9,0 gramas (nove gramas) de maconha, acondicionadas em dois invólucros plásticos, além de 02 (dois) rolos de papel filme, 01 (uma) caixa de aparelho celular Iphone com resquícios de droga, diversos sacos zip, 02 (dois) fragmentos plásticos com resquícios de droga, um pote de vidro com resquícios de droga, uma máquina de cartão e uma faca. A apreensão dos entorpecentes em variedade e quantidade razoável, as circunstâncias em que se deu a apreensão, assim como os petrechos encontrados na residência do denunciado, evidenciam que a substância entorpecente apreendida tinha como destino a mercancia ilícita. Foi requisitado laudo pericial da droga sintética apreendida e petrechos utilizados no preparo do entorpecente - fls. 112/113." Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial

Após regular citação apresentado defesa preliminar (fls. 279/285), sobre a qual o Ministério Público se manifestou (fls. 291/292), o despacho de fls. 293/298, de 17 de setembro de 2021, recebeu a denúncia e determinou a produção de provas. Na instrução do feito ouviram-se as testemunhas arroladas pelas partes e foi o réu regularmente interrogado (fls. 338/340); além e ter sido processado o incidente de verificação de dependência em apenso, com laudo pericial devidamente homologado, dando o réu como imputável com relação aos fatos da denúncia.

Em alegações finais, o nobre Dr. Promotor de Justiça (fls. 389/398) pediu: "Ante o exposto, requer o Ministério Público que o pedido da ação penal seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE para CONDENAR o réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe as penas conforme exposto neste memorial, por ser a medida de justiça. No mais, requeiro o encaminhamento de cópia reprográfica da denúncia, da ata da audiência realizada, da mídia da audiência, bem como termo de declarações de fls. 08, para a Delegacia de Polícia para instauração de inquérito policial para apuração do crime de falso testemunho por Lucas Tondati Garcia." Por

sua vez, o ilustre Dr. Defensor (fls. 402/432) bateu-se: "Ante o exposto, requer-se a Vossa Excelência: Ante aos motivos expostos requer-se a incidência da fixação da pena mínima, conforme visto alhures; Com a fixação da pena mínima, fato este viável, pois, as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/2.006, lhes SÃO FAVORÁVEIS, como também sua PRIMARIEDADE, não tendo quaisquer antecedentes, REQUER-SE ainda a incidência ao disposto no artigo 33 § 4º da Lei n.º 11.343/06, pois, NÃO INTEGRA QUALQUER ASSOCIAÇÃO PARA O FIM DE TRÁFICO, MUITO MENOS EXISTE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS OU A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA; Diante do exposto, também faz jus a dita causa de diminuição de pena, pois, é PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES; Assim, além da pena mínima em razão das circunstâncias judiciais favoráveis a sua pessoa, a REDUÇÃO deverá abranger o GRAU MÁXIMO, isto é, 2/3 (dois terços). Por fim, requer-se que a pena aplicada (PRIVATIVA DE LIBERDADE) seja SUBSTITUÍDA por DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, a serem fixadas em sede de execução. ITA SPERATUR JUSTITIA! FIAT JUSTITIA, PEREAT MUNDUS!"

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade dos fatos narrados na denúncia e imputados ao réu, encontra-se suficientemente demonstrada nos autos pelo auto de exibição e apreensão de fls. 36/39; pelas fotos de fls. 40/51; pelo laudo pericial de fls. 54/57, que concluiu: "Item A (Acondicionado sob o lacre 0026489) Descrição: 2 (dois) invólucro(s) plástico(s) do tipo "filme" retorcido encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos. Massa Bruta e/ou Quantidade: 60,31 grama(s) - sessenta gramas e trinta e um centigramas. Massa Líquida: 55,53 grama(s) - cinquenta e cinco gramas e cinquenta e três centigramas. Quantidade retirada para análise e/ou contra-perícia: uma amostra de aproximadamente 2 g (dois gramas) foi aqui retirada para análises, sendo o remanescente destas análises armazenado sob a forma de contraperícia. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de teste colorimétrico e , foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020). O restante do item (material, invólucro(s) e lacre(s)) foi devolvido à autoridade policial requisitante nos termos das exigências legais, sob o lacre número 1460610. Item B (Acondicionado sob o lacre 0026490) Descrição: 2 (dois) invólucro(s) plástico(s) do tipo "filme" retorcido encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos. Massa Bruta e/ou Quantidade: 80,5 grama(s) - oitenta gramas e cinquenta centigramas. Massa Líquida: 74,11 grama(s) - setenta e quatro gramas e onze centigramas. Quantidade retirada para análise e/ou contra-perícia: uma amostra de aproximadamente 2 g (dois gramas) foi aqui retirada para análises, sendo o remanescente destas análises armazenado sob a forma de contraperícia. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de teste colorimétrico e , foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020). O restante do item (material , invólucro(s) e lacre(s)) foi devolvido à autoridade policial requisitante nos termos das exigências legais, sob o lacre número 1460610. Item C (Acondicionado sob o lacre 0026492) Descrição: 2 (dois) invólucro(s) plástico(s) do tipo "filme" retorcido encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos. Massa Bruta e/ou Quantidade: 11,87 grama(s) - onze gramas e oitenta e sete centigramas. Massa Líquida: 7,85 grama(s) - sete gramas e oitenta e cinco centigramas. Quantidade retirada para análise e/ou contra-perícia: uma amostra de aproximadamente 2 g (dois gramas) foi aqui retirada para análises, sendo o remanescente destas análises armazenado sob a forma de contraperícia. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de teste colorimétrico e , foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020). O restante do item (material , invólucro(s) e lacre(s)) foi devolvido à autoridade policial requisitante nos termos das exigências legais, sob o lacre

número 1460610. Item D (Acondicionado sob o lacre 0026494) Descrição: 9 (nove) invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por pressão (tipo "zip") encerrando porção de material sólido particulado, de cor branca. Massa Bruta e/ou Quantidade: 8,25 grama(s) - oito gramas e vinte e cinco centigramas. Massa Líquida: 4,16 grama(s) - quatro gramas e dezesseis centigramas. Quantidade retirada para análise e/ou contra-perícia: uma amostra de aproximadamente 2 g (dois gramas) foi aqui retirada para análises, sendo o remanescente destas análises armazenado sob a forma de contraperícia. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada Delgada (CCD - cilcohexano:tolueno:dietilamina) e foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020). O restante do item (material, invólucro(s) e lacre(s)) foi devolvido à autoridade policial requisitante nos termos das exigências legais, sob o lacre número 1460610. Item E (Acondicionado sob o lacre 0026493) Descrição: 1 (um) invólucro(s) plástico(s) do tipo "filme" retorcido encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos. Massa Bruta e/ou Quantidade: 9,55 grama(s) - nove gramas e cinquenta e cinco centigramas. Massa Líquida: 6,59 grama(s) - seis gramas e cinquenta e nove centigramas. Quantidade retirada para análise e/ou contra-perícia: uma amostra de aproximadamente 2 g (dois gramas) foi aqui retirada para análises, sendo o remanescente destas análises armazenado sob a forma de contraperícia. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de teste colorimétrico e, foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020). O restante do item (material, invólucro(s) e lacre(s)) foi devolvido à autoridade policial requisitante nos termos das exigências legais, sob o lacre número 1460610"; pelo laudo pericial em telefone celular de fls. 194/275; além da prova oral carreada para os autos.

Antes de passar a análise do mérito, anoto que a defesa não postulou em sede de alegações finais a absolvição do réu, e deixa assentado a ocorrência do delito de tráfico na conduta do réu e sua autoria, posto que pugna apenas por fixação da pena com o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

E, a prova dos autos, de forma segura e convincente demonstra a ocorrência dos fatos como narrados na denúncia, a configuração do delito de tráfico de drogas; a autoria deles pelo réu e a inexistência de qualquer causa de exclusão de ilicitude. O investigador de polícia Willian Gomes da Silva Namura, narrou nos autos que a investigação se iniciou a partir de denúncia anônima na DISE, que retratava que Alex, de veículo Jetta branco, realizava o tráfico de drogas, com indicação do endereço onde ocorria o tráfico. No local realizaram diligências prévias e constaram que havia o veículo Jetta branco, consultaram a placa, estava em nome de Marlene da Silva Gomes e ela tem filho de nome Alex da Silva Gomes. Fizeram campanhas em diversos dias e verificaram movimentação típica de tráfico de drogas, como "entra e sai" de gente na porta. Alex saía muito com o carro dele e o acompanharam para verificar o roteiro que ele fazia e que era rápido. Visualizaram ele em outra observação no posto onde ele foi surpreendido no dia da prisão. Em 07 de maio surpreenderam um rapaz chamado Fábio com maconha e que havia comprado de Alex de um jetta branco, de cútis branca, tatuado e por volta de 40 anos de idade. Havia câmera que filmou a ação do Jetta branco chegando e entregando um pacote ao indivíduo e logo após os policiais prenderam o rapaz de moto. Havia grande movimentação em frente à casa de Alex no dia dos fatos. Seguiram Alex até o endereço de Bruno e logo após Alex já saiu no carro dele. Havia um Ford Ka branco em frente à casa do Bruno, que é do filho do Alex. Alex saiu do local, retornou para a casa dele e saiu de novo, logo parou ao lado do posto onde já o viram estacionar várias vezes. Alex saiu do carro jetta com o entorpecente na mão, entregou-o ao Lucas e este lhe deu o dinheiro. Realizaram a abordagem deles. Encontram o entorpecente com Lucas, o dinheiro com Alex e perguntaram se havia mais entorpecente com ele, ao que Alex disse que era só usuário. Acionaram mais equipes. O cachorro do BAEP encontrou mais droga na casa de Alex, petrechos para preparar drogas e dinheiro. Outra equipe abordou Bruno e encontrou mais porção de droga com

ele. Havia mais droga embaixo do banco do passageiro e mais dois comprimidos aparentemente de ecstasy no carro de Alex. O laudo pericial do celular de Alex trouxe vasto material relacionado ao tráfico e indicava que realmente Lucas fez a negociação com o Alex. Lucas havia feito contato com Douglas. Douglas fala para Alex que um colega de confiança ia buscar maconha com ele. Depois Lucas entra em contato com Alex e combina a entrega da droga. Bruno trabalhava para Alex fazendo as entregas de drogas, conforme vislumbraram pelo laudo do aparelho de telefone celular de Alex. No celular de Alex tem vídeos filmando tijolos de maconha. Não identificaram onde fica o "guarda-roupa" que o Alex se refere nas mensagens e que nele guardaria a droga. Não fez a abordagem do Bruno. Fez a abordagem do Alex e do Lucas. O policial Luís que abordou o Bruno. Lucas estava com muito medo, falou que era usuário, que havia comprado a droga de Alex e que tinha medo de "caguetar". Lucas falou na Delegacia que ia buscar "seda", mas não tinha. Visualizou Alex entregando droga ao Lucas.

O investigador de polícia Luís Henrique Pancott declarou que um mês antes desses fatos havia ocorrido flagrante do Fábio e do Yago e eles falaram que compraram a droga de Alex do jetta branco. Um mês após chegou a denúncia sobre Alex e jetta branco que efetuava o tráfico de drogas no Bongiovani. Foram apurar a denúncia. Fizeram campanhas no local. O investigador William o chamou para diligenciar na residência. A equipe foi ao local. Alex foi à residência do Bruno e lá permaneceu por algum tempo. Alex voltou à residência dele e depois foi ao encontro do Lucas, que estava em um posto no bairro. Flagraram Alex entregando entorpecente ao Lucas. Ambos diziam que eram usuários. Lucas disse que foi lá comprar uma seda. Retornaram à residência do Alex com apoio do canil. Abordaram Bruno, que estava com um Ford Ka branco que era de um dos filhos do Alex. Inicialmente Lucas disse que comprou droga do Alex, o que o depoente e o outro policial presenciaram. Deu para ver que era droga que Alex entregou ao Bruno. Encontraram também entorpecente embaixo do banco do Alex. Outra equipe abordou Bruno e o depoente foi apoiar a equipe. Bruno disse que era usuário e conhecia Alex, mas estava com o Ford Ka para conserto. Bruno não disse que comprou droga com Alex. Tinha cocaína na residência de Alex e dois comprimidos de ecstasy no carro de Alex, que o cachorro encontrou. O investigador William analisou o laudo do celular e realizou o relatório de investigação. A policial militar Gisele Ferreira de Oliveira, narrou nos autos que trabalha no canil do 8º BAEP. Estava em serviço na data e foi ao local com a sua cachorra e o parceiro com o cão dele. Foi à casa indicada e fizeram a varredura com a sua cachorra. A cachorra encontrou droga no guarda-roupa e, embaixo do tapete do jetta branco, dois comprimidos de ecstasy. Quando chegaram na casa tinham várias viaturas e pessoas na sala aguardando.

Esses relatos, em única voz, confirmam que os fatos se passaram como narrados na denúncia, que se configuram o delito de tráfico de drogas e autoria deles pelo réu Alex.

O depoimento dos policiais é suficiente para alicerçar a culpa do acusado, que deve provar sua inocência com os meios que obtiver.

Transcrevo decisões a respeito do crime ora tratado, relativamente à impossibilidade de desclassificação para uso de entorpecente, bem como sobre a credibilidade da palavra dos policiais envolvidos com a descoberta e detenção dos envolvidos:

"PROVA - Depoimento de policial que efetuou a prisão em flagrante - Declarações harmônicas e seguras - Suporte suficiente à condenação - Inteligência dos artigos 6º, III, e 202 do CPP. PROVA - Depoimento de policial - Credibilidade dos testemunhos em geral enquanto não apresentada razão concreta de suspeição. ((RT 668/275 - TJSP - rel. Des. Jarbas Mazzoni))."

"Prova criminal - Testemunha - Hipótese de Tóxico. Depoimentos prestados por policiais. Validade. Presunção 'iuris tantum' de agirem escorreitamente no exercício da função. ((RJTJSP 125/563))."

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento

testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. ((STF HC 74.608-0 de São Paulo rel. Min. Celso de Mello DJU 11.04.97, pág. 12.189))”.

A testemunha Lucas Tondati Garcia, que na fase policial confirmou a condição de traficante do réu, dando detalhes de transação de drogas que teve com ele e que foi constatada em seu celular, mentiu em juízo para desfazer as declarações da polícia e procurar afastar a condição de traficante do réu.

Entretanto, os demais elementos de provas autos, principalmente, neste ponto, o pericial, constata e revela o tráfico na conduta do réu e a transação de drogas entre o réu Alex e a testemunha Lucas Tondati. E, revela seu falso depoimento. Ao ser interrogado sobre os fatos, o réu, confessando a posse das drogas como afirma a denúncia, negou a condição de traficante, narrando que em sua residência havia cocaína e maconha para o seu uso; é dependente há muito tempo. Não vendeu droga a Lucas e a Bruno. Eles são seus conhecidos. Foi em uma festa “rave” e, depois, esqueceu os comprimidos de ecstasy embaixo do banco do seu veículo. Foi buscar um refrigerante no posto perto de sua casa. Avisou ao Lucas para encontrá-lo lá, mas não chegou a conversar com ele. A polícia abordou Lucas e depois o interrogando.

Nesse narrativa do réu de ter a droga para consumo próprio, está afastada pelo riqueza de detalhes do tráfico nos depoimento dos policiais, pelas narrativa das testemunhas, embora modificadas em juízo, bem como pelas conversa existente no celular do réu e demonstrada pelo laudo pericial.

O laudo pericial dos aparelhos de telefones celulares apreendidos revela diálogos entre o usuário Lucas Tondati Garcia e o réu ALEX (fls. 199/200), nos quais ALEX expressamente negocia a venda de substância entorpecente ao referido usuário no mesmo dia da prisão em flagrante nestes autos (fls. 224/225) e também a outros contatos nos dias 12 e 14 de julho de 2021 ALEX negocia a venda de drogas (fls. 224/237, 256/257, 260/261). No referido laudo há mensagens em que o réu ALEX conversa acerca da contabilidade de vultosos valores evidentemente relacionados ao comércio espúrio de entorpecentes com o contato “W Tost”, além de diversos diálogos sobre transporte, venda e fornecimento de drogas com os contatos “W Tost” (fls. 226/237), “Caio” (fls. 245/247), “Sapapata Dolgui” (fls. 248/250), “Barti 22” (fls. 250/251), “Gf” (fls. 251/253), “Meu Godim” (fls. 253/254), “18 99625-8489” (fls. 254/255), “Spok 2” (fls. 257/259), “Lamberson” (fls. 259/260) e “Rudd” (fls. 262/264), demonstrando nítido envolvimento do réu com a prática do tráfico de drogas.

A perícia encontrou várias fotografias armazenadas no celular do réu ALEX de elevada quantidade de substâncias semelhantes a drogas de variados tipos, pesadas e embaladas para a comercialização, com balanças e facas utilizadas para fracionamento das drogas, ostentação de quantias em dinheiro, armas de fogo (fls. 209/218 e 223), anotações contábeis indicativas de comércio de drogas (fls. 219/237).

Quanto à destinação dos entorpecentes apreendidos nos autos, imperioso salientar que o elemento subjetivo do tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos não é perceptível logo de início, mas através das circunstâncias externas do caso concreto, as quais acabam por traduzir a intenção do agente.

Na hipótese dos autos, a droga apreendida, aliada ao modo como foram encontradas, denota sua destinação ao comércio ilegal.

É o quanto basta para embasar a condenação.

Nesse sentido: “CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Circunstâncias que induzem a caracterização do delito. A existência de denúncias anônimas, a diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, parte embalada e pronta para a venda clandestina, são circunstâncias que induze a caracterização do tráfico.” (Apelação Criminal n.º 223.036-3 - Sorocaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 01.07.97 - V.U.);

“TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Circunstâncias que evidenciam a condição de

traficante - Recurso não provido. Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu, no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a sua prisão." (Apelação Criminal n.º 152.279-3 - Marília - 3ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 19.06.95 - V.U.). "ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas - Prova - Confissão policial de co-réu - Retratação judicial isolada - Palavra de policiais - Validade - Quantidade e modo de acondicionamento que revelam o fim de comércio - Flagrante preparado - Inocorrência - Pena - Pretendida substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Crime hediondo - Regime integralmente fechado - Manutenção - Recursos não providos." (Apelação Criminal n. 281.880-3 - Guaratinguetá - 4ª Câmara Criminal - Relator: Passos de Freitas - 08.02.00 - V.U.).

Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado

Nesse sentido: "Não é indispensável a aprova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (TJSP RT 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3,3.8.94, p.8745); "Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão" (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

Por tudo isto é que é de rigor a procedência da ação penal, com a condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas, do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosagem da pena.

No tocante à circunstância específica prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, no aumento da pena base em decorrência da quantidade, da diversidade das drogas e sua natureza das mesmas; e a aplicação desses mesmos motivos, quantidade, diversidade e natureza das drogas para negar a redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem-se que não é possível por violar o princípio do bis idem bis.

"Habeas corpus. 2. Dosimetria. 3. Tráfico de drogas. 4. A quantidade de drogas, por si só, não pode proporcionar a presunção de que o paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 5. Quantidade da droga valorada na primeira e na terceira fase da dosimetria. Bis in idem. Desproporcionalidade no cálculo. 6. Ordem concedida para que seja refeita a dosimetria, nos termos do acórdão. (STF; HC 145362, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Julgado em 04/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020).

Neste ponto, é forçoso reconhecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos HCs n.º 112776 e n.º 109193, em 19/12/2013, decidiu que não é possível a utilização cumulativa da quantidade e da natureza da droga na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer em bis in idem: "[...] HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. BIS IN IDEM. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º, DO ART. 2º, DA LEI 8.072/1990. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância

sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto. 2. O magistrado sentenciante considerou a natureza e a quantidade de droga simultaneamente na primeira e na terceira fase de individualização da reprimenda, em flagrante bis in idem. [...]" (HC 112776, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

Também decidiu: "[...] HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA SOMENTE NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRIÇÃO DE DIREITOS. PACIENTE CONDENADO À PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, I, DO CP. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto. 2. No caso, a natureza da droga apreendida foi utilizada somente na terceira etapa da dosimetria, ou seja, para fixar o fator de redução da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6, não havendo, portanto, violação ao princípio do ne bis in idem. [...]" (HC 109193, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

Portanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de bis in idem caso a mesma circunstância (quantidade e natureza da droga) seja utilizada nas primeira e terceira fases da dosimetria, mas admitiu que tal circunstância possa ser avaliada em qualquer delas (desde que apenas em uma).

Presente a causa de diminuição em comento, entendo que a quantidade e a natureza da droga devem ser levadas em consideração apenas na terceira fase, para fins de estabelecimento do quantum de redução da pena, pois, caso contrário, conforme reconheceu o próprio STF, "o julgador ficaria limitado a aplicar, indistintamente, a maior fração a todos os condenados que tivessem jus à redução, a acarretar uma uniformidade de apenamento, em flagrante violação dos princípios da isonomia, da proporcionalidade, da legalidade, da motivação e da individualização da pena".

"PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. MODULAÇÃO PELA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO APRECIADA NEGATIVAMENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o entendimento firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (ARE 666334/RG), a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas tanto na primeira fase, para elevação da pena-base, quanto na terceira etapa, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Todavia, devem ser consideradas apenas em uma das fases, sob pena de bis in idem. [...]" (Acórdão n. 1122497, 20170110292870 APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA



CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: 169/173) "[...] 3. O Supremo Tribunal Federal entendeu que caracteriza bis in idem a análise da natureza e da quantidade da droga na primeira fase da dosimetria, para aumentar a pena-base, e também na terceira, para graduar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. [...]" (Acórdão.1110966, 20160110770556APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/07/2018, Publicado no DJE: 30/07/2018. Pág.: 97/114).

Ressalte-se que esse entendimento prevalece mesmo que os citados elementos (quantidade e natureza da droga) sejam cindidos em diferentes circunstâncias ou fases."[...] 1 - As circunstâncias especiais - natureza e quantidade da droga - devem ser examinadas conjuntamente, não podendo ser consideradas, cumulativamente, na primeira e na terceira fases da individualização da pena, pena de caracterizar bis in idem. [...]" (Acórdão.1112143, 20170110075896APR, Relator JAIR SOARES, Revisora: MARIAIVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2018, Publicado no DJE: 01/08/2018. Pág.: 165/181)."[...] 4. De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, a valoração da natureza e quantidade da substância entorpecente na primeira etapa da dosimetria para subsidiar a fixação de pena-base acima do piso legal, bem como para graduar a diminuição da pena diante do privilégio estatuído no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 configura bis in idem. Não se admite a separação dos vetores - quantidade e natureza - para esse fim. [...]" (Acórdão.1077373, 20160110898110APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: 298/324).

A jurisprudência entende que, à míngua de critérios fornecidos pelo legislador, devem ser observadas a quantidade e a natureza da droga como critério de fixação da fração de redução da pena:"[...] 3 A redução da pena pela fração mínima prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, se justifica pela natureza e quantidade das drogas apreendidas. [...]"(Acórdão n.994019, 20130111131885APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisora: SANDRA DE SANTIS, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: 244/255).

"[...] 5. Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não comprovada a dedicação a atividades ou organizações criminosas, aplica-se a causa de diminuição prevista no § 4º, art. 33, da LAD, porém, pela metade, tendo em vista a quantidade e a natureza da droga. [...]"(Acórdão n.953819, 20150110790220APR, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: ROBERVALCASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/07/2016, Publicado no DJE: 13/07/2016. Pág.: 99/126).

Portanto, levando-se em consideração a quantidade de drogas apreendida, entendo que a aplicação da causa especial de diminuição de pena em comento na fração de 1/2 (metade) mostra-se proporcional.

Nesse sentido:[...] 1. Não sendo a quantidade de droga apreendida irrelevante (720,88g de massa líquida de maconha), razoável a incidência da fração de ½ (metade) de diminuição (§4º do artigo 33 da LAD). [...]" (Acórdão1160518, 20180110068803 APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: 152/174)."[...] 5. Na hipótese de reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, a quantidade da droga apreendida (588g de maconha) justifica a redução da pena no patamar de 1/2 (metade). [...]" (Acórdão 1123911, 20170110259838 APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisora: NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no DJE: 17/9/2018. Pág.: 186/198).

"[...] 3 A dosimetria é irretocável quando a pena é fixada no mínimo legal nas duas primeiras fases e foi reduzida por metade na fase final, considerando a diversidade de drogas apreendidas e a sua natureza. [...]" (Acórdão 1000569, 20130110716564 APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/3/2017, publicado no DJE: 9/3/2017. Pág.: 57/74).

Nesse cenário, deve ser mantida a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração de 1/2 (metade). Portanto, na dosagem da pena, levo em consideração que o réu é primário e não registra antecedentes, e as

circunstancias judiciais do artigo 59, lhe são favoráveis, fixo a pena base no mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Na segunda fase, ausentes quaisquer circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira e última fase, presentes os requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que é aplicável a causa de diminuição de pena nele estabelecida. Com efeito, a par da primariedade técnica, não se evidenciou ser o acusado pessoa dedicada a atividades criminosas ou integrante de organização criminosa.

As quantidades de drogas e de dinheiro apreendidos em poder do réu são diminutas, sendo possível crer que ele não se trata de criminoso contumaz.

Reduz-se, pois, em razão da quantidade de droga apreendida, a pena na proporção de 1/2 (metade), de modo a resultar em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagar 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia, tornando-a definitiva neste ponto, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, deve-se ponderar que, no julgamento do HC n. 111.840/ES, realizado em sessão extraordinária do dia 27/06/2012, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei n. 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, assim, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e outros a eles equiparados (os dados são do HC n. 312.654-SP, STJ, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 12/02/2015). No caso concreto, considerando não só a primariedade e a ausência de antecedentes, mas também, a circunstância de não ser considerada a quantidade de droga e o pouco de dinheiro apreendido com o réu, entende-se viável a fixação do regime inicial aberto.

Por outro lado, levando em conta as circunstâncias judiciais favoráveis, conforme antes apontado, entende-se também cabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.

Há orientação jurisprudencial nesse sentido:

"Tráfico de drogas. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Elementos de prova suficientes para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Pena-base fixada no mínimo legal. Causa de aumento, prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, que não se afigurou. Afastamento. Réus que preenchem os requisitos para a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Circunstâncias do crime que tornam proporcional a diminuição na fração máxima de 2/3. Fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão, ex officio, da pena exclusiva em restritiva de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Detração determinada. Analogia ao artigo 42 do CP. Apelo parcialmente provido para esses fins. (TJSP, Apelação n. 0070062-66.2010.8.26.0050, rel. Otávio de Almeida Toledo, j. 13/12/2011).

E ainda: Entorpecente Absolvição ou Desclassificação - Impossibilidade - Provas seguras que demonstram a prática do delito de tráfico. Penas fixadas no mínimo e aplica do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 no percentual de 1/5 - Redução em 2/3 Possibilidade. Penas. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Cabimento. Regime prisional inicial fechado Fixação conforme preceitua o § 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07 Apelação do réu provida parcialmente." (TJSP, Apelação n. 0006628-72.2010.8.26.0319, rel. Pedro Menin, j. 10/04/2012).

Assim, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo

tempo da pena aplicada, e por uma pena pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente na data do pagamento em favor do Hospital do Câncer de Presidente Prudente.

Em caso de revogação das penas restritivas de direitos, o réu cumprirá a pena corporal fixada nesta sentença no regime aberto.

ISTO POSTO e o que mais dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu ALEX SILVA GOMES, RG: 29.957.871, Data Nascimento: 06/02/1980.

Naturalidade: PRESIDENTE PRUDENTE -SP Nome do Pai: EDSON ROSA GOMES e Nome da Mãe: MARLENE DA SILVA GOMES, a cumprir a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e por uma pena pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente na data do pagamento em favor do Hospital da Esperança de Presidente Prudente (Hospital do Câncer); e a pagar a multa de valor correspondente a 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, cada dia no valor mínimo legal, por violação do artigo 33, caput, c/c o artigo 33, § 4º, ambos da Lei nº 11.343/2006.

INCONTINENTI, expeça-se alvará de soltura em favor do réu, ante a qualidade do regime prisional adotado neste momento, encaminhando ao presídio em que se encontra recolhido para o devido cumprimento.

Determino a imediata destruição dos aparelhos celulares apreendidos nos autos posto que utilizados para o tráfico conforme demonstrou a perícia neles realizada.

Condeno o réu a pagar as custas processuais.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça.

Publique-se,

Registre-se,

Comunique-se e

Intimem-se.

Presidente Prudente, 18 de outubro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA